

1500339-49.2022.8.26.0571

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ANDRE LUIS BASTOS

Comarca: Itapetininga

Foro: Foro de Itapetininga

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 09/06/2022

... são condutas comuns aos delitos de tráfico ilícito e uso indevido, do que resulta, pelo princípio da exclusão, quando não se tratar de uso indevido, reconhecer o narcotráfico. Caracteriza o delito de tráfico ilícito de substância entorpecente trazer consigo, sem autorização legal ou regulamentar, maconha e cloridrato de cocaína, em doses unitárias, de pequenos embrulhos, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itapetininga

Foro de Itapetininga

1ª Vara Criminal

Av. Peixoto Gomide, s/nº, ., Centro - CEP 18200-160, Fone: (15) 3511-2411,

Itapetininga-SP - E-mail: Itapet1cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo Digital nº:

1500339-49.2022.8.26.0571

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial (Flagrante) - 23469065 -

DEL.SEC.ITAPETININGA, 1305/22/300 - DEL.SEC.ITAPETININGA, 2064664 - DISE-

DEL.SEC.ITAPETININGA, 1305/22/300 - DISE- DEL.SEC.ITAPETININGA, 2064664/2022 -

DISE- DEL.SEC.ITAPETININGA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MAGNO LUIZ FRANCO DE MORAIS

Réu Preso

Aos 09 de junho de 2022, às 16:30h, na sala de audiências da 1ª Vara Criminal do Foro de Itapetininga, Comarca de Itapetininga, Estado de São Paulo, sob a presidência do(a) MM. Juiz(a) de Direito Dr(a). ANDRE LUIS BASTOS, comigo Escrevente ao final nomeado. Presentes o acusado MAGNO LUIZ FRANCO DE MORAIS acompanhado de seu defensor público, Dr(a). Mariela Moni Marins Tozetto, e o DD. Promotor de Justiça Dr. Célio Silva Castro Sobrinho. Antes de iniciados os trabalhos a defensora pública entrevistou-se com o réu, pela plataforma da Microsoft Teams, em contato reservado. Pelo MM. Juiz foi dito que: audiência realizada por videoconferência, utilizando-se a ferramenta Microsoft Teams, sendo que os depoimentos colhidos nesta data foram importados e vinculados ao SAJ. Em seguida, com as formalidades legais e com a anuência das partes e do réu, passou o MM. Juiz a tomar os depoimentos, todos colhidos através da ferramenta Microsoft Teams, os quais foram gravados de forma individual e ao final, identificados, para

que não houvesse risco de perda de gravação caso a solenidade fosse gravada apenas em arquivo único. Iniciados os trabalhos, pelo MM. Juiz foi colhido o interrogatório do réu e em seguida colhidos os depoimentos de 02 (duas) testemunhas de acusação, arroladas em comum com a defesa do réu. Indagado novamente o réu se queria acrescentar algo em seu depoimento, o mesmo disse que sim, sendo dada a palavra. Em seguida, pelo MM. Juiz foi dito que, não havendo mais provas a serem produzidas, dava por encerrada a instrução criminal e dava a palavra às partes para apresentação de alegações finais. Dada a palavra ao Dr. Promotor de Justiça, pelo mesmo foi dito: MM. Juiz: acha-se processado o acusado como incurso no artigo 33 da Lei de Tóxicos, em face dos fatos detalhadamente narrados na denúncia. Concluída a instrução, a ação penal merece proceder. A materialidade delitiva encontra respaldo no laudo de exame químico-toxicológico acostado aos autos. Autoria e existência delitiva, ao seu turno, vêm comprovadas nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório. Ouvidos em juízo, os policiais responsáveis pela prisão do réu narraram, em tom unânime, que realizavam patrulhamento quando notaram o acusado, quando avistaram o acusado, sendo certo que ao realizarem a abordagem ele tentou se evadir, sendo, contudo, detido próximo a um terreno, e no trajeto dispensou algum objeto. Depois de detido, verificaram que o pacote que havia dispensado continha as porções de entorpecentes, sendo, então, preso em flagrante. As palavras dos policiais revestem-se de imensurável valor probatório, uma vez que isentas e desprovidas de qualquer intenção de prejudicar o agente. Demais disso, não há nenhum elemento capaz de indicar uma suposta suspeição do policial; ao contrário, revela de forma absolutamente convincente toda dinâmica da diligência que resultou na prisão em flagrante. O acusado, ao seu turno, afirmou que estava ali para usar drogas, negando que fosse seu o entorpecente apreendido e também que estivesse no local para o tráfico. Entretanto, sua versão não há de merecer credibilidade, pois as circunstâncias envolvidas da abordagem, apreensão dos entorpecentes, e, principalmente, a quantidade e forma na qual estava acondicionado o entorpecente revelam, de modo inequívoco, que se destinavam ao comércio espúrio. Dessa forma, é patente a responsabilidade penal do acusado. Demonstradas autoria e materialidade, pugna a Justiça Pública pela procedência da ação penal, condenando-se o acusado nos termos da denúncia, devendo, ademais, ser fixado regime inicial fechado para o débito da sanção privativa de liberdade. Dada a palavra à Defensora do réu, pela mesma foi dito: MM. Juiz: Segundo consta na denúncia, o dia 08 de março de 2022, nesta cidade e comarca, o Acusado tinha trazia consigo drogas para fins de tráfico. Em disso foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06. O acusado foi notificado e apresentou sua defesa preliminar. A audiência de instrução, debates e julgamento foi realizada em 09 de junho de 2022, oportunidade em que foram ouvidas as testemunhas arroladas na denúncia e o réu foi interrogado. A testemunha PM narrou que o réu, ao visualizar a viatura, adentrou no terreno e teria deixado algo da cintura. Em revista o réu tinha vinte reais consigo. Verificaram o pacote e encontraram os trinta e dois pinos. Narrou que antes da aproximação da viatura havia várias pessoas na rua, porém, focaram no réu, por conta da atitude suspeita de tentar se afastar da viatura. Ao ser interrogado, Magno alegou que tinha ido ao local para comprar drogas para consumir, porém, a pessoa que ia vender saiu correndo e deixou as drogas para trás. Nega ser proprietário dos entorpecentes localizados pelos policiais. É o breve relatório.

INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. A versão apresentada pelas testemunhas acusatórias não é suficiente para demonstrar além de qualquer dúvida razoável que o Acusado estivesse envolvido na prática do crime de tráfico de drogas. Primeiramente, veja-se que não há indícios suficientes de que o acusado estava praticando o crime de tráfico de drogas, sendo certo que sua versão não foi infirmada pelo restante da prova coligida. Verifica-se, nesse ponto, que o Acusado, desde a fase policial, nega peremptoriamente ser o proprietário da droga localizada dentro do terreno, informando que apenas trazia consigo vinte reais para comprar drogas para usar, porém, não chegou a conseguir comprar, haja vista a chegada dos policiais. Por outro lado, ninguém presenciou a localização de drogas no terreno, sendo certo que sequer o réu foi visto ingressando ou saindo do local específico. Trata-se de terreno, área vasta, onde, de acordo com os próprios PMs a prática de tráfico de

drogas é intensa, de modo que os estupefacientes lá localizados poderiam pertencer a qualquer pessoa. Ainda, segundo os próprios policiais, não houve campana, de modo que inexisteu qualquer observação prévia que pudesse concretizar a alegação de que o acusado estava atuando na venda de entorpecentes. Ante ao exposto, entende-se que o cotejo da prova no caso concreto não satisfaz o standard probatório apto à condenação do Acusado, razão pela qual se requer a improcedência da ação penal, nos moldes do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDOTA. A acusação é improcedente e deve ser desclassificada para a conduta descrita no art. 28 da Lei n. 11.343/06. Com efeito. Com efeito, o Acusado tinha em sua posse baixa quantidade de droga, a qual reconheceu que lhe pertencia e era destinada ao uso. Em outras palavras, a versão do Acusado, ou seja, de que estava ali para adquirir drogas para o próprio consumo não foi infirmada pela prova acusatória. Assim, requer a desclassificação do crime para a conduta descrita no art. 28, caput, da lei de Drogas e consequentemente seja declarada sua inconstitucionalidade, por violação ao princípio da vedação de punição à autolesão. Subsidiariamente, na hipótese de condenação, em respeito ao princípio da eventualidade, passa-se à análise da dosimetria da pena a ser imposta ao acusado. Na primeira fase, pleiteia-se a fixação da pena-base no mínimo legal, ante a ausência de requisitos capazes de exasperá-la, nos termos do art. 59 do Código Penal. Muito embora o artigo 42 da Lei de Drogas estabeleça como critério para a dosagem da pena a quantidade e a variedade de entorpecentes apreendidos, é impossível a aplicação de tal norma, na medida em que é difícil avaliar qual quantidade e quais variedades de drogas seriam suficientes para justificar a aplicação da causa de diminuição abaixo do máximo estabelecido em lei. Assim, a inexistência de tal parâmetro faz com que a aplicação de pena seja feita de maneira completamente arbitrária. Na segunda fase, não incidem agravantes, porém, está presente a atenuante da idade do réu, que tinha apenas 20 anos na data dos fatos (fls. 16). Na terceira fase, de rigor a aplicação do redutor do tráfico, nos termos do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06. Vejamos: Veja-se que não ficou comprovado nos autos que se dedique a práticas criminosas ou que integre organização criminosa, preenchendo então, todos os requisitos do redutor. Aqui, deve ser observada a regra de tratamento que emana da presunção do estado de inocência, não podendo se admitir que processos ainda em tramitação sejam utilizados para presumir-se a dedicação do Réu em atividades ilícitas. Com efeito, o fato de o Acusado responder a outro processo não o impede de receber o redutor do artigo 33, § 4º da Lei de Drogas, com base no princípio da presunção do estado de inocência que somente é afastado com condenação judicial definitiva, nos moldes da mais recente interpretação do E. Supremo Tribunal (HC 187.180/SP. Rel. Min. Gilmar Mendes. Data de julgamento: 19/06/2020). É justamente por essas razões, amparadas em precedentes da E. Suprema Corte, que se requer a aplicação da causa de diminuição prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06. Quanto ao regime inicial, nos termos do artigo 33 do Código Penal, requer seja fixado o regime aberto para cumprimento da pena. Isso porque, a fixação de regime fechado como decorrência automática do disposto no artigo 2º da Lei n. 8.072/90 contraria o princípio da individualização da pena, previsto no artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal. Cumpre ressaltar que o Plenário do C. Supremo Tribunal Federal, durante o julgamento do Habeas Corpus nº 111.840, em sessão realizada no dia 27 de junho de 2012, declarou incidentalmente a inconstitucionalidade do parágrafo 1º do artigo 2º da Lei n. 8.072/90, com redação dada pela Lei n. 11.464/07, o qual prevê que a pena por crime hediondo (inclusive tráfico de drogas) será cumprida, inicialmente, em regime fechado. De tal forma, ante as peculiaridades do caso em tela, claro está que não há razão para a determinação de regime fechado, ainda que não se aplique o redutor em seu grau máximo. Não obstante, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC 596.603/SP assentou o entendimento de que condenados por tráfico privilegiado possuem direito subjetivo ao cumprimento da pena em regime inicialmente aberto. Cabível, ainda, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, haja vista que o artigo 44 foi considerado inconstitucional pelo E. STF (HC n. 97.256/RS), o que motivou a expedição da Resolução n. 05, de 2012, do Senado Federal, suspendendo, nos termos do art. 52, X,

da CF a expressão “vedada a conversão em penas restritivas de direitos do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06”. No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC 596.603/SP assentou o entendimento de que condenados por tráfico privilegiado possuem direito subjetivo à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Diante do exposto, requer sejam acolhidas as teses defensivas, nos termos da fundamentação supra. Por fim, requer seja concedido o direito de recorrer em liberdade, bem como a gratuidade de justiça, com isenção de custas processuais, por se tratar o acusado de pessoa hipossuficiente nos termos da lei. A seguir pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte decisão: MAGNO LUIZ FRANCO DE MORAIS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33 da Lei 11.343/06, sob a acusação de que, no dia 08 de março de 2022, na Rua Alice de Almeida Fernandes n. 100, nesta cidade, trazia consigo, para fins de tráfico, 32 porções de cocaína. O feito foi regularmente processado encerrando-se a instrução nesta data com alegações finais do MP e da Defesa. Eis, em síntese, o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. O presente processo foi instaurado para apuração da responsabilidade penal do réu no tocante à prática do delito de tráfico ilegal de entorpecentes. A materialidade restou incontroversa ante a apreensão da droga e o laudo acostado aos autos. O réu, em seu interrogatório judicial alegou que a droga não era de sua propriedade. Os policiais ouvidos em juízo relataram que estavam em patrulhamento quando viram o réu, já conhecido nos meios policiais; que ao avistar a viatura Magno saiu correndo e dispensou uma sacola que trazia na cintura, sendo, porém, alcançado e detido; que a sacola dispensada foi recuperada e tinha em seu interior 32 porções de cocaína. Finalizada a instrução, temos que o conjunto probatório leva à conclusão de que o réu é responsável pela prática do delito; a assertiva é lógica e harmoniza-se com os elementos colhidos no decorrer do feito. A quantia de droga encontrada, as circunstâncias da prisão e as declarações dos policiais evidenciam a finalidade de tráfico. A prova oral colhida, à luz do contraditório e as demais provas acostadas aos autos, formam um conjunto apto à formação de um juízo de convencimento quanto ao tráfico exercido pelo réu. Vale citar: “Adquirir, guardar ou trazer consigo, sem autorização legal ou regulamentar, substância entorpecente, são condutas comuns aos delitos de tráfico ilícito e uso indevido, do que resulta, pelo princípio da exclusão, quando não se tratar de uso indevido, reconhecer o narcotráfico. Caracteriza o delito de tráfico ilícito de substância entorpecente trazer consigo, sem autorização legal ou regulamentar, maconha e cloridrato de cocaína, em doses unitárias, de pequenos embrulhos, embalagem usual do varejo das drogas” (TJRJ - AC 1.185/93 - Rel. Enéas Machado Cotta - TDTJRJ 23/288). Vale dizer que a lei pune o tráfico ilícito de entorpecente em qualquer de suas condutas, típicas e exclusivas. Em tema de entorpecente, a conduta de guardar, sem autorização legal ou regulamentar, a droga proibida, basta para integrar a figura criminosa do tráfico ilícito. Vale, ainda, mencionar que nenhuma restrição merecem os depoimentos de policiais, mormente quando suas declarações vêm corroboradas por outros elementos de prova e também quando não levantada qualquer suspeita fundada e demonstrada. Nesse sentido: “nenhum impedimento legal existe ao testemunho de investigadores e pessoas ligadas à polícia. Seus depoimentos devem ser considerados, examinados e pesados em cada caso, como o de outra testemunha qualquer. Nunca, porém, sumariamente afastados como de todo imprestáveis. Desde que verossímeis, coerentes e não desmentidos pelo restante da prova, podem servir de base à decisão condenatória.” (Ap.Crim. 103.701 TJSP). “ a simples condição de policial não torna a testemunha suspeita ou impedida” (STF – RT 68/64). “ não existe motivo algum a ensejar a desvalia do depoimento policial. Seria um contra-senso credenciar o Estado alguém a atuar em seu nome e, depois, negar-lhe crédito, quando, perante o mesmo Estado-Juiz, viesse relatar seus atos de ofício. Por isso, totalmente superada a tese do desprestígio do relato policial na moderna jurisprudência. O agente de segurança é testemunha como as demais. Submete-se a compromisso e terá seu depoimento avaliado no cotejo de todas as provas sem plus-valia, mas também sem preconceito. ” (TACRIM-SP JUTACRIM 30/221). A negativa do réu resta isolada e descasada da realidade fática, não merecendo um mínimo de credibilidade. O réu é tecnicamente primário, porém ostenta condenação por tráfico em grau de recurso, o que denota que se dedica

a atividades criminosas; consigne-se, ainda, que o réu ostenta mais de vinte passagens pela vara da infância e juventude pela prática de atos infracionais, o que também evidencia que é voltado à prática de ilícitos, o que leva ao afastamento do privilégio, fls 29/32. Nesse sentido a 3 S. do STJ em julgamento recente, RESP 1.916.596. Rel Min Laurita Vaz, em 08 de setembro de 2021, já se manifestou que atos infracionais podem ser considerados para afastamento do privilégio. Posto isso, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado narrada na denúncia e CONDENO o réu MAGNO LUIZ FRANCO DE MORAIS, qualificado nos autos, como incurso no art. 33 da Lei 11.343/06. Ante a condenação, custas pelo réu, ficando suspensa a exigibilidade de pagamento em face dos benefícios da justiça gratuita deferidos nos autos. Fica decretado o perdimento dos objetos e valores apreendidos nos termos da Lei de Tóxicos. DOSIMETRIA DA PENA. Atento aos critérios estipulados no artigo 59 do Código Penal, fixo a pena base no mínimo legal, a saber: CINCO ANOS DE RECLUSÃO e multa de QUINHENTOS DIAS MULTA, cada qual no seu mínimo legal. Não existem agravantes a serem consideradas. Não existem atenuantes a serem consideradas. Não existem causas de aumento ou causas de diminuição a serem consideradas. Não havendo incidência de qualquer outro instituto penal a influenciar na quantificação da reprimenda torno DEFINITIVA A PENA DE CINCO ANOS DE RECLUSÃO e multa de QUINHENTOS DIAS MULTA, cada qual em seu patamar mínimo. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos por restarem não atendidos os requisitos do art. 44 do Código Penal, ante o quantum da pena; anote-se ainda que o regime de cumprimento fixado para o tráfico de entorpecentes, e a própria natureza do delito, que é móvel de grande parte de outros crimes cometidos para a manutenção do vício, além do quantum da pena, impedem a concessão da benesse por restarem desatendidos os requisitos necessários. Pelas mesmas razões, resta desatendido o inciso II do art. 77 do Código Penal, inviabilizando a suspensão condicional da pena. Fixo, como regime inicial de cumprimento de pena, o REGIME FECHADO; a devida e necessária reprovabilidade da conduta do réu, concretamente demonstrada nos autos pela apreensão da droga não merece o abrandamento do regime prisional; além da quantia da pena, mais de quatro anos, as circunstâncias da prisão e gravidade da conduta que fica evidenciada pela quantia de droga que seria distribuída a inúmeros consumidores, demonstram a intensidade da violação do bem jurídico protegido pela norma, evidenciando a necessidade de uma resposta estatal adequada e condizente. Nesse sentido: " ... O tráfico ilícito de entorpecentes é o grande mal da sociedade contemporânea; faz adoecer de forma grave e muitas vezes irreversível, parte expressiva da população; instiga e propicia a prática de vários outros delitos, até mais graves; vitima a juventude e prejudica seu desenvolvimento; desagrega famílias e relacionamentos; multiplica a indigência.." (HC 517.885-SP 2019/0184021-7). Não se trata de argumentação genérica, o acima citado é fato diariamente constatado na região onde este magistrado atua há mais de vinte anos e infelizmente constata os efeitos do consumo de drogas e o consequente aumento do tráfico de drogas fomentado por entregas constantes de entorpecentes para abastecimento de "biqueiras" existentes em todos os municípios. Anoto, ainda, pela experiência vivida na região, a cooptação de menores que iniciam suas trajetórias infracionais no tráfico de drogas e após a maioridade incidem e reincidem na prática de crimes num ciclo vicioso e infundável de praticas ilícitas, o que efetivamente aponta a gravidade da conduta perpetrada e justifica a fixação do regime mais gravoso. Os motivos acima elencados justificam a fixação do regime fechado e passam ao largo da gravidade abstrata do tráfico de drogas. O réu permaneceu preso em razão de preventiva decretada durante o decorrer do feito; tal fato, aliado à pena imposta, regime inicial de cumprimento fixado, não substituição e a inexistência de qualquer alteração da situação que gerou a determinação de seu recolhimento cautelar, indica que a situação atual deve ser mantida; anote-se, ainda, que a prisão deve ser mantida para assegurar a aplicação da lei penal, ante o acima exposto. Recomende-se o réu na prisão onde se encontra. Oportunamente, esgotadas as vias ordinárias, providencie-se o necessário para efetivo cumprimento da sanção imposta, arquivando-se o feito com as cautelas devidas. Publicada em audiência, saem os presentes intimados, nos termos do art. 392 do CPP. Cumpra-se. Remeta-se o feito

para degravação por estenotipia ante a necessidade de manutenção mínima da prática conforme orientação do Setor. O resultado da presente audiência foi informado às partes, saindo os presentes intimados, dispensada a assinatura em razão de tratar-se de processo digital. Nada mais. Eu, ALINE CRISTIANE ROCHA MEIRA RAMOS, escrevente, digitei.

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANDRE LUIS BASTOS

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA